



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0007544-21.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erica Regina Colmenero Coimbra**

Vistos.

Vistos

FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA e FELIPE RODRIGO JACO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33 *caput*, da Lei 11.343/06 e artigo 333, *caput*, c.c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, sob acusação de, no dia 23 de julho de 2016, por volta das 17:00 horas, na Estrada Saturnino Pereira, altura do nº 10, Iguatemi, nesta cidade e comarca de São Paulo, foram surpreendido quando traziam consigo, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, 204 (duzentos e quatro) porções (trouxinhas de papel), contendo 165g (cento e sessenta e cinco gramas) aproximadamente, de cocaína, substância esta droga e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local já mencionados, os acusados Fernando e Felipe, ofereceram e prometeram vantagem indevida a funcionário público para determina-lo e omitir ato de ofício.

A denúncia foi devidamente recebida em 24 de agosto de 2016, determinando a citação e intimação dos acusados para apresentarem resposta à acusação, bem como designou data para audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2016. O acusado Felipe apresentou defesa prévia fls. 134/142. Por sua vez o acusado Fernando, apresentou resposta à acusação em fls. 182/188.

0007544-21.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha de acusação. Ante a ausência das demais testemunhas redesignou-se a audiência para o dia 25 de novembro de 2016.

Nesta, foram inquiridas as testemunhas faltantes e ao final foram interrogados os réus. Após encerrada a instrução processual o Ministério Público e a defesa do acusado Fernando ofereceram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A Defesa do réu Fernando, por seu turno, manifestou-se contrariamente, pleiteando a absolvição do acusado por falta de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, impugnando os depoimentos prestados pelos Policiais Militares. Em teses subsidiárias, requer que seja a pena base fixada em seu mínimo; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06; que seja fixado o regime menos gravoso para o cumprimento da pena; que seja a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos; bem como seja facultado ao acusado o direito de apelar em liberdade. A defesa do acusado Felipe, em memoriais escritos, pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 18/19), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 210/212) e demais laudos periciais (235/238, 239/242 e 243/250), bem como prova oral produzida nos autos.

A autoria, por seu turno, também é certa, devendo ser atribuída ao acusados no que tange o crime de tráfico de drogas. Fato este que não se confirma em relação ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

crime de corrupção ativa, que deve ser atribuído apenas ao corréu Felipe. Vejamos.

A testemunha Policial Militar **SARA BARBOSA**, ouvida em Juízo, reconheceu os réus. Na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina quando avistou dois indivíduos em um veículo Gol. Os indivíduos tentaram se evadir quando notaram a presença da polícia. Foi realizada a abordagem. Na posse do réu Felipe foram encontradas, no bolso da roupa, 201 porções de substâncias que aparentava ser cocaína. Com o outro, indivíduo nada foi localizado de ilícito, assim como no interior do veículo. Após ser dada voz de prisão Felipe ofereceu dois mil reais para ser liberado. Tal oferecimento foi comunicado aos superiores hierárquicos da depoente. O réu Felipe pediu para fazer uma ligação. Na Delegacia uma mulher se aproximou e entregou um envelope para o policial Jean que acompanhava a depoente na diligência. O corréu Fernando nada declarou. Felipe disse que era morador das proximidades e que havia acabado de pegar a droga. Às perguntas da acusação respondeu que a mulher que havia entregue o envelope relatou que recebeu R\$ 20,00 de um desconhecido para entregar o pacote. Às perguntas da defesa respondeu que Fernando demonstrou muito nervosismo no momento da abordagem, tudo indicando que tinha ciência do porte de drogas. Aponta que como o réu não portava documento, Felipe efetuou a ligação, para pedir que alguém o trouxesse, e nesse momento acabou fazendo o pedido para que se levasse o dinheiro. Em nenhum momento ele pediu dinheiro para pagamento de fiança.

A testemunha Policial Militar **JEAN CARLO VIEIRA**, ouvido em juízo, reconhece os réus. Afirma que os réus estavam em um veículo prata que trafegava pela contramão. Lembra-se que abordou o veículo. Recorda-se que Felipe era o condutor. Foram achadas drogas no bolso de ambos réus. Eles usavam bermuda e todas as drogas estavam nos bolsos. Recorda-se que tratava de cocaína. Eram muitas porções e tinha uma porção maior para ser dividida. Felipe perguntou se podiam trocar uma ideia, ofereceram dinheiro, sem especificar qualquer quantia. Fernando ouviu tudo. O comando foi acionado e orientou a algema-los e leva-los ao DP. Na Delegacia surgiu uma mulher que entregou uma bolsa dizendo que na favela mandaram que ela entregasse ao depoente aquele dinheiro para liberarem os réus. O escrivão foi testemunha da prisão. Às perguntas da acusação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

respondeu que ambos teriam oferecido dinheiro. Ambos teriam confessado informalmente que traficavam. Às perguntas da defesa respondeu não se recordar do horário da abordagem. Apontou que foi Felipe quem, com seu próprio celular, fez uma ligação. Reafirma que não chegou a falar em valores.

A testemunha de Defesa Tenente Marques, ouvido em Juízo, confirma que se tratava de uma ocorrência de tráfico. Relata que o policial entrou em contato com ele e avisou que um dos réus teria oferecido certa quantia em dinheiro para ser libertado. Orientou o policial a conduzir os envolvidos à Delegacia. Tomou conhecimento posteriormente, que uma pessoa surgiu na Delegacia de Polícia levando dinheiro. O contato foi via telefone. Às perguntas da Defesa respondeu que não estava no local dos fatos. Relata que foi apenas contatado sobre a ocorrência de corrupção e que esse contato é comum no dia-a-dia.

A testemunha de Defesa MARIA NILZA DA CONCEIÇÃO, ouvido em Juízo, conhece apenas Felipe. Não conhece Fernando. Na data em que ele foi preso a mãe do Felipe pediu seiscentos reais emprestados para ela.

A testemunha MARIA JOSINEIDE DE OLIVEIRA LIMA, ouvida em Juízo, só conhece Felipe. Não viu quando o réu foi preso. Não conhece Fernando. Na data em que ele foi preso a mãe do Felipe pediu duzentos reais emprestados para ela, segundo ela, para pagar fiança. Relata que ele é usuário de drogas, mas não trafica.

A informante do juízo KELLY CRISTINA DE LIMA, é esposa de Felipe, e ouvida em Juízo como informante, disse que recebeu uma ligação e um policial que pedia dois mil reais como pagamento de fiança pela liberá-lo de uma prisão. O policial não se identificou. Pediu dinheiro emprestado para sua sogra. Relata que chegou a conversar com seu marido pelo telefone. Disse que não quis ir à delegacia e mandou um “menino” levar o dinheiro até a Delegacia de Polícia.

A testemunha de defesa ROSINEIDE MARIA JACÓ, ouvida em Juízo como informante, é mãe do réu Felipe. Relata que no dia dos fatos seu filho estava usando seu carro, pois ele iria consertar o pneu. Afirma que seu filho é usuário de entorpecentes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Afirma que a esposa dele lhe procurou pois precisava de dinheiro para pagar uma fiança. Foi requerido o valor de R\$ 2.000,00. Pediu ajuda para outras pessoas vizinhas e juntou o dinheiro.

O réu FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, na data dos fatos, pediu carona ao corréu Felipe. Em dado momento, foram até a “lojinha”. Felipe comprou duas porções. No momento em que o traficante estava entregando a droga a polícia surgiu. O traficante se assustou e jogou as drogas que vendia no interior do carro de Felipe. Após a abordagem, um dos policiais usou o celular de Felipe para pedir dois mil reais a título de fiança para que fossem libertados. Trabalha em um lava-rápido. Já foi processado por furto tentado.

O réu FELIPE RODRIGO JACÓ, em seu interrogatório judicial, afirma que no dia dos fatos sua mãe tinha pedido para ele arrumar o carro dela. Afirma ser usuário de entorpecentes. Naquele dia estava comprando quatro pinos de cocaína. O traficante viu a polícia e jogou a sacola de drogas do carro do interrogando. Fernando estava no veículo. Tentou fugir da polícia, porém foi abordado. As drogas estavam no carro, pois o traficante jogou. Trabalha como ajudante geral em construção civil. No momento em que o revistaram, os policiais usaram o celular do depoente. Falaram com sua esposa. Segundo o policial, a esposa do depoente teria dinheiro para liberá-lo. Foi o policial quem disse que o dinheiro seria para fiança. Não conhece a mulher que levou o dinheiro à Delegacia de Polícia. Às perguntas da acusação respondeu que em nenhum momento ofereceu qualquer valor ao policial. Naquele dia deu apenas carona ao Fernando. Ambos iriam usar drogas. Ele é usuário também. Às perguntas da defesa, respondeu que não sabe se o traficante é menor de idade.

Não obstante as teses defensivas, os depoimentos dos policiais militares encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos, não desqualificando-os o fato das testemunhas serem policiais. Ademais, não houve demonstração concreta de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam os policiais interesse em prejudicarem os acusados. Nesse contexto, em sendo agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição relevante ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo.

Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados pelos milicianos, sendo que os pontos conflitantes, entre eles, não podem ser considerados vitais para afastar um decreto condenatório, isto porque é notório o grande número de ocorrências similares pelas quais os policiais militares participam todos os dias.

Dessa forma, prevalece a versão policial eis que imparcial. Nesse diapasão: *“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”* (HC 76.608-0 – STF – DJU 11.04.97).

E ainda: *“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, 34 E 35, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/06. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. 1. A ausência de indicação precisa dos temas não enfrentados pelo Tribunal de origem implica deficiência de fundamentação do recurso especial, a atrair o óbice constante da Súmula 284/STF. 2. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. 3. O crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas. No caso, tendo as instâncias ordinárias, após exame das provas dos autos, constatado a existência de estabilidade e permanência entre o agravante e outros indivíduos, inviável a reversão do julgado ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. O depoimento de policiais, quando em conformidade com as demais provas dos autos, é elemento idôneo a subsidiar a formação da convicção do julgador. (...)”.(STJ: AgRg no AREsp 303213 SP 2013/0063139-3, **Relator** Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - T5 - QUINTA TURMA. **Publicação** DJe 14/10/2013.)*

Outrossim, o fato típico foi descrito de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela prisão dos réus, quer seja, que na posse dos réus (trazer consigo) foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, bem como no veículo em que se encontravam.

Nesse aspecto, o elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado. A absolvição alvitada pelas defesas dos corréus é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório no que tange o crime de tráfico de drogas. O depoimento dos policiais, como dito outrora, é de inegável valor probante e evidencia a ocorrência do crime. A intenção de tráfico se verificou pela quantidade de droga encontrada em poder dos corréus, bem como a forma de acondicionamento do produto, o que comprova que a droga era destinada ao comércio. Logo, de rigor a condenação.

Aliás, a hipótese de que os réus portavam drogas para uso próprio, não se sustenta, haja vista que nada impede que o usuário de drogas realize o comércio do entorpecente até como forma de sustentar o próprio vício.

Vale ressaltar que a versão apresentada pelos réus não apresenta qualquer guarida. Em verdade, é importante frisar que a versão apresentada pelos acusados na fase inquisitiva foi diversa daquela indicada em Juízo o que acaba por descreditar tais versões por eles apresentadas. Noutro giro, repise-se a firmeza e unicidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policiais, o que lhes confere grande crédito, pois guardam grande conexão com os demais elementos probatórios juntados aos autos.

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado aos acusados, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Quanto ao crime de corrupção ativa tem-se que a versão apresentada pelos acusados tampouco convence. Entendo, porém, que deve ser atribuído apenas a Felipe, haja vista que não há elementos que Fernando tenha praticado ou concorrido para a prática deste crime. Importante ressaltar que todo o procedimento de oferecimento e obtenção do valor se deu por comando de Felipe e ainda todo o valor apreendido para tal fim foi juntado por conhecidos de Felipe. Assim é de se concluir, em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa (sendo que duas delas foram ouvidas como informantes do Juízo), que não há certeza quanto a real participação do corréu Fernando quanto à prática do crime de corrupção ativa. Dessa forma, inviável se mostra sua condenação por tal crime, ante a ausência da certeza necessária que o decreto condenatório impõe.

As provas dos autos demonstraram inequivocamente que o réu Felipe cometeu o crime de corrupção ativa, pois os policiais foram firmes e unânimes em afirmar que o réu ofereceu a quantia em dinheiro para ser liberado.

Ademais, não há que se esquecer que uma pessoa foi à Delegacia de Polícia entregar dinheiro ao policial e nesse momento foi detida e posteriormente liberada. Tal fato, apenas reafirma a versão policial apresentada. Ademais, tratando-se de crime formal ocorreu a consumação no momento do oferecimento da quantia para não ser preso, independentemente do desdobramento dos fatos. A valoração da prova é feita pelo Juízo, por ocasião do julgamento.

Novamente, saliente-se que, gozam os policiais dos “adjetivos atribuíveis à autêntica testemunha”, presumindo-se a legitimidade dos atos que, enquanto servidores públicos, praticam no exercício de suas funções. Assim, tratando-se de presunção relativa, à defesa cumpria afastar a veracidade de tais depoimentos, demonstrando sua dissonância no tocante ao contexto probatório ou o particular interesse dos milicianos na solução da causa.

A propósito: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes (TACRIM-SP – AP – Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).” (in “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, v. 2, Alberto Silva Franco e outros, 2ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1.933).

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado aos acusados, bem como o crime de corrupção ativa, em relação apenas ao corréu Felipe, o decreto condenatório é medida que se impõe. Atendendo ao **método trifásico de aplicação da pena**, passo a fixá-la.

Na **primeira fase**, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus são primários e não possuem antecedentes. Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, perfazendo o total de **05 anos de reclusão e multa de 500 dia-multa para o crime de tráfico e a pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa em relação ao crime de corrupção ativa**.

Na **segunda fase**, verifico que não há causas agravantes, nem atenuantes a serem aplicadas.

Na **terceira fase** não há causas de aumento de pena a ser aplicada.

Existe, porém causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto os acusados são primários, e ao que constou não registram antecedentes hábeis a impedir a aplicação do benefício, bem como não há nos autos demonstração qualquer de que integrem organização criminosa e se dediquem às atividades ilícitas. Ademais, verifico que a quantidade de droga apreendida está dentro da normalidade para traficantes da espécie. Portanto, para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reduzo a pena anteriormente fixada, quanto ao crime de tráfico, em 2/3 (dois terços), perfazendo o montante final de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**.

Entendo que o **regime mais adequado** ao cumprimento da reprimenda corporal seja o **fechado**, não se podendo falar, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em casos como o trazido a julgamento,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Explico.

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa **empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da **Resolução n.º 5/12**, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Em outra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “*esvaziamento*” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “**empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

No caso dos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso, embora a pena aplicada permita, objetivamente, referida fixação, nos termos do artigo 33, e incisos, do Código Penal.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, pois o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, conseqüentemente, desestruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais.

Aliás, deve ter em mente que não se trata de um direito subjetivo do acusado à fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (*“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*).

A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, *in verbis*: *“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar”* (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei).

Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haveria outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea *a*, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo **não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Diante do exposto, **julgo parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA e FELIPE RODRIGO JACO**, qualificado nos autos, como **incursos no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-os a cumprir, em estabelecimento penal adequado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, ausente notícia de fortuna dos réus**. Ainda, **CONDENO o corréu FELIPE RODRIGO JACÓ a cumprir a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de corrupção ativa, igualmente em regime fechado**. Nesse contexto, **ABSOLVO o corréu FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA da prática do crime de corrupção ativa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal**. Conforme fundamentado acima, deverão iniciar o cumprimento das penas em **regime fechado**.

Responderam ao processo presos, com mais razão, que após decreto condenatório, sejam assim mantidos, motivo pelo qual **nego o apelo em liberdade**.

Ademais, ainda persistem os elementos ensejadores da decretação da prisão preventiva, haja vista que, caso sejam soltos, poderão vir a tentar frustrar a execução da pena, evadindo-se do distrito da culpa.

DECLARO, ainda, a perda da importância aprendida em favor da União,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nos termos do artigo 92. Tais valores serão revertidos ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, de acordo com o artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contra-prova.

Em caso de recurso, EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, com urgência.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 20 de janeiro de 2017.

Erica Regina Colmenero Coimbra
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**